



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Resolución

Número:

Referencia: EX-2019-68067694- -APN-DGD#MPY - OPI. 331

VISTO el Expediente N° EX-2019-68067694- -APN-DGD#MPYT, y

CONSIDERANDO:

Que en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442 procede su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 7° a 17 y 80 de la Ley N° 27.442.

Que la operación traída a consulta el día 29 de julio de 2019, consiste en la adquisición por parte de la firma INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION, de todas las acciones comunes emitidas y a emitirse de la firma RED HAT, INC.

Que la firma MARCOPOLO S.A. ya ostentaba control conjunto sobre ambas empresas con anterioridad a la transacción que se notifica.

Que la operación fue implementada a través de un Acuerdo y Plan de Fusión celebrado entre las firmas INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION, SOCRATES ACQUISITION CORP. y RED HAT, INC. en fecha 28 de octubre de 2018.

Que el contenido de la documentación, cuya eximición de traducción fuera solicitada por las consultantes, fue satisfecho con la información aportada por las mismas mediante la copia simple del documento original en inglés, de donde surge la fecha de cierre de la operación, por un lado, y el valor de las ventas netas globales.

Que el cierre de la citada operación se produjo el día 9 de julio del 2019.

Que, en la operación traída a consulta, el volumen de negocios de las firmas involucradas es superior al umbral previsto en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA emitió el Dictamen de fecha 26 de febrero de 2020, correspondiente a la “OPI. 331”, aconsejando a la señora Secretaria de Comercio Interior disponer que la operación traída a consulta, consistente en la adquisición por parte de la firma INTERNATIONAL BUSINESS MACHONES CORPORATION de todas las acciones comunes emitidas y a emitirse de la firma RED HAT, INC. se encuentra sujeta a la obligación de notificar estipulado por el Artículo 9 de la Ley N° 27.442; ordenar la apertura de un nuevo expediente electrónico de concentraciones económicas con el formulario F1 presentado por el consultante el día 29 de julio del 2019 junto con la solicitud de opinión consultiva tratada en el presente dictamen y acumularlo al presente expediente; y eximir al consultante, en virtud de lo establecido en el apartado b), punto c) del Anexo I de la Resolución N° 40 de fecha 22 de febrero de 2001 de la ex SECRETARÍA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DEL CONSUMIDOR del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, de acompañar la traducción pública del Anexo 1.a) y del Anexo 1.b) de la presentación efectuada con fecha 8 de octubre de 2019.

Que la suscripta comparte los términos del mencionado dictamen al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en la Ley N° 27.442, el Artículo 5° de Decreto N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018, el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019.

Por ello,

LA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Ordénase la apertura de un nuevo Expediente Electrónico bajo el Código de Trámite “MPYT00003 –Notificación de Concentraciones Económicas”, incorporando al mismo el Formulario F1 presentado por la firma INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION el día 29 de julio del 2019 junto con la solicitud de opinión consultiva.

ARTÍCULO 2°.- Ordénase la tramitación conjunta del expediente cuya apertura se refiere el artículo precedente, al expediente de la referencia.

ARTÍCULO 3°.- Exímase a la firma mencionada en el Artículo 1° de la presente medida, de acompañar la traducción pública del Anexo 1.a) y del Anexo 1.b) de la presentación efectuada con fecha 8 de octubre de 2019.

ARTÍCULO 4°.- Hácese saber a las consultantes que la operación traída a consulta, consistente en la adquisición por parte de la firma INTERNATIONAL BUSINESS MACHONES CORPORATION de todas las acciones comunes emitidas y a emitirse de la firma RED HAT, INC. se encuentra alcanzada por la obligación de notificación dispuesta en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 5°.- Hácese saber a las consultantes que la presente opinión consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el expediente citado en el Visto, por lo que si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ellos tornarían inaplicables los conceptos aquí vertidos.

ARTÍCULO 6°.- Considérase al Dictamen de fecha 26 de febrero de 2020, correspondiente a la “OPI. 331”, emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO que, como Anexo IF-2020-12589018-APN-CNDC#MDP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 7°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 8°.- Comuníquese y archívese.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Dictamen firma conjunta

Número:

Referencia: OPI 331- Dictamen artículo 9 de la Ley 27.442

EX-2019-68067694- -APN-DGD#MPYT| (OPI 331)

SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos a su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones que tramitan bajo el expediente EX-2019-68067694-APN-DGD#MPYT (OPI. 331) del Registro del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, caratulado “OPI N° 331 - INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION S/ OPINIÓN CONSULTIVA ART. 10° DE LA LEY 27.442” iniciadas en virtud de la consulta promovida en los términos del Artículo 10 de la Ley N° 27.442 por la firma INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION.

I. SUJETOS INTERVINIENTES EN LA TRANSACCIÓN Y SU ACTIVIDAD

I.1. Participantes de la Operación

1. INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION (en adelante, "IBM") es una compañía abierta y cuya sede social se encuentra en Armonk, Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica. IBM se encuentra activa a nivel global en el desarrollo, producción y comercialización de una gran variedad de soluciones de tecnología de la información (“IT” por sus siglas en inglés), principalmente software y sistemas de IT empresarial, y servicios de IT.

2. En Argentina, IBM se encuentra activa a través de: IBM Argentina S.R.L. (en adelante IBM ARGENTINA), una compañía de responsabilidad limitada constituida bajo las leyes de Argentina y registrada por ante la Inspección General de Justicia (en adelante IGJ). IBM ARGENTINA provee soluciones a sus clientes con la asistencia de tecnologías de información avanzada, incluyendo software, hardware, servicios de consultoría, y soluciones de almacenamiento.

3. Por su parte, RED HAT, INC. (en adelante RED HAT) es una compañía estadounidense que provee

productos de Software de código abierto a la comunidad empresarial. RED HAT provee soluciones de código abierto, utilizando un enfoque dirigido a sus clientes para proveer tecnologías de alto rendimiento como Linux, cloud, y Kubernetes. Su sede social se encuentra en Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos de Norteamérica.

4. En Argentina, RED HAT se encuentra activa a través de: RED HAT DE ARGENTINA S.A. (en adelante RED HAT ARGENTINA), una compañía constituida bajo las leyes de Argentina, registrada por ante la IGJ.

5. El Objeto de la Operación

6. La transacción consiste en la adquisición, por parte de IBM, de todas las acciones comunes emitidas y a emitirse de RED HAT (en adelante LA TRANSACCIÓN).

II. LA OPERACIÓN SUJETA A CONSULTA

7. LA TRANSACCIÓN fue implementada a través de un Acuerdo y Plan de Fusión celebrado entre IBM, SOCRATES ACQUISITION CORP., (en adelante SOCRATES ACQUISITION) y RED HAT celebrado en fecha 28 de octubre de 2018.

8. SOCRATES ACQUISITION, una subsidiaria de propiedad exclusiva de IBM, se fusionará con y en RED HAT, resultando RED HAT la sociedad absorbente que se convertirá en última instancia en una subsidiaria de propiedad exclusiva de IBM.

9. De acuerdo a lo informado por las partes, el cierre de la operación se produjo el 9 de julio del 2019¹ y se presentaron el 29 de julio solicitando opinión consultiva.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN PLANTEADA

10. Analizadas las presentaciones efectuadas, resulta necesario aclarar que esta opinión consultiva reconoce como único sustento fáctico las circunstancias relatadas en las sucesivas presentaciones. En consecuencia, cualquier omisión o desarrollo que no se ajuste a las presentaciones y que pudieren implicar una modificación de las condiciones descriptas que se valoran en este dictamen, determina la inaplicabilidad de la presente al caso en estudio.

11. En cuanto la cuestión planteada, el consultante entiende que la operación de concentración económica descripta no se encuentra alcanzada por la obligación de notificar establecida en el Art. 9 de la Ley N° 27.442 (en adelante, "LDC"), dado que la Transacción no encuadra dentro de las disposiciones del Artículo 9 de la LDC debido a que la excepción de minimis, del artículo 11 inciso e del mismo cuerpo normativo, es aplicable.

12. Cabe recordar que la LDC —a diferencia de la normativa que la antecedió— ha instituido un mecanismo que permite la actualización anual de los umbrales de notificación y de la excepción de minimis. Ello es así porque los montos de los umbrales en cuestión han sido establecidos en una unidad de cuenta definida como «unidad móvil». Al respecto, el Artículo 85 de la norma estipula que "...el valor de la unidad móvil será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial

que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web."

13. Suplementariamente, debe tenerse presente que el 25 de abril de 2019, el Secretario de Comercio Interior dictó la Resolución 145/2019, cuyo Art. 1 establece "... para el año 2019 el valor de la unidad móvil definida en el Artículo 85 de la Ley N° 27.442, en la suma de PESOS VEINTISÉIS CON CUARENTA CENTAVOS (\$ 26,40)."

14. Se aprecia entonces que existe la obligación de efectuar la notificación cuando el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles —monto que, a partir del dictado de la Resolución SCI N° 145/19, equivale a \$ 2.640.000.000— y la transacción no se encuentre alcanzada por alguna de las excepciones previstas en el Art. 11 de la LDC.

15. Dado que, en la operación traída a consulta, el volumen de negocios de las empresas involucradas no se indica como inferior a los umbrales previstos en el Artículo 9° de la LDC, se determinará con precisión si la operación consultada encuadraría en la exención prevista en el inciso e) del artículo 11 de la LDC.

16. Las Partes entienden, tal como se analizará a continuación, que la Transacción no encuadra dentro de las disposiciones del Artículo 9 de la LDC debido a que la excepción de minimis enunciada en el artículo 11 inciso e), de la misma ley, es aplicable. El mencionado artículo establece que "Se encuentran exentas de la notificación obligatoria prevista en el artículo 9° de la presente ley, las siguientes operaciones: (...) e) Las operaciones de concentración económica previstas en el artículo 7° que requieren notificación de acuerdo a lo previsto en el artículo 9°, cuando el monto de la operación y el valor de los activos situados en la República Argentina que se absorban, adquieran, transfieran o se controlen no superen, cada uno de ellos, respectivamente, la suma equivalente a veinte millones (20.000.000) de unidades móviles, salvo que en el plazo de doce (12) meses anteriores se hubieran efectuado operaciones que en conjunto superen dicho importe, o el de la suma equivalente a sesenta millones (60.000.000) de unidades móviles en los últimos treinta y seis (36) meses, siempre que en ambos casos se trate del mismo mercado. A los efectos de la determinación de los montos indicados precedentemente, el Tribunal de Defensa de la Competencia informará anualmente dichos montos en moneda de curso legal que se aplicará durante el correspondiente año. A tal fin, el Tribunal de Defensa de la Competencia considerará el valor de la unidad móvil vigente al último día hábil del año anterior."

17. En cuanto al "valor de los activos" del objeto, que en este caso es RED HAT, acorde a lo informado por el consultante, el valor de los mismos se encuentra valuado en US\$ 11.900.000, lo cual está por debajo del monto establecido en la normativa, que equivale a \$ 528.000.000 . El tipo de cambio utilizado se corresponde a la fecha en la cual se emitieron los estados contables de RED HAT. Por lo tanto, debido que el 28 de febrero de 2019, el tipo de cambio era de U\$ 1 = \$ 40.10 , los activos de RED HAT estaban valuados en \$ 477.190.000 , lo cual se encuentra por debajo del tope legal de \$ 528.000.000 . ²

18. Por otro lado, en lo relativo al "monto de la operación" en Argentina, el mismo no fue determinado por las empresas al momento del cierre, es decir, en el instrumento de la operación no se ha asignado un monto a la porción argentina del negocio. Siendo que la excepción "de minimis" es, de hecho, una excepción, la

misma se debe interpretar restrictivamente. Es decir, si las partes de la operación pretenden la aplicación de una excepción a la obligación de notificar, deben ser ellos mismos quienes presentan toda la documentación e información pertinente para probar fehacientemente que la excepción a la regla se aplica a ellos y que no se encuentran en la obligación de notificar.

19. Ahora, para aquellos casos en que las empresas no asignan un valor local a la operación, esta Comisión utilizó históricamente un enfoque³ que establece que “la porción local del precio de compra” resulta de multiplicar el cociente del monto total de la transacción sobre la facturación total del negocio adquirido, por las ventas argentinas del negocio adquirido. Aplicando este enfoque en el expediente actual, se puede concluir que el valor local de la transacción asciende al monto de US\$ 193.760.000, que en pesos argentinos se traduce a un monto total de \$ 8.292.928.000.⁴ Dicho monto supera ampliamente el umbral de 20.000.000 de unidades móviles establecido en el artículo 11 de la LDC para que aplique la excepción de minimis.

20. De acuerdo a lo que surge de los estados contables correspondientes al ejercicio económico finalizado el 28 de febrero del 2019, las ventas y servicios netos de RED HAT ARGENTINA suman un total de \$ 763.198.496,46 , traduciéndose en US\$ 19.032.381.⁵ A su vez, el precio global de LA TRANSACCIÓN fue de aproximadamente US\$ 34.600.000.000; el valor de las ventas y los servicios netos de RED HAT ARGENTINA al 28 de febrero de 2019 ascendieron a US\$ 19.032.381, y los ingresos totales de RED HAT, INC. al finalizar el ejercicio económico finalizado el 28 de febrero de 2019, ascendieron a US\$ 3.362.069.000.

21. Por lo tanto, y teniendo en cuenta lo declarado por las partes consultantes, cabe concluir que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a veinte millones (20.000.000) de unidades móviles —monto que, a partir del dictado de la Resolución SCI N° 145/19, equivale a \$ 528.000.000—, y pesa sobre ella la obligación de notificación prevista en el Artículo 9 de la LDC.

IV. PROCEDIMIENTO

22. El día 29 de julio de 2019, se presentó INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION ante esta Comisión Nacional, a fin de requerir una opinión consultiva respecto de la obligación de notificar una operación de concentración económica, en los términos del Artículo 10 de la Ley N° 27.442.

23. Con fecha 15 de agosto de 2019, esta Comisión Nacional efectuó un requerimiento al consultante, comunicándole que el plazo establecido en el Artículo 8 del «Anexo I» del Decreto N° 89/2001 y apartado a.4. del Anexo I de la Resolución SCT N° 26/2006 no comenzará a correr hasta tanto no se dé cumplimiento a lo solicitado.

24. Luego de sucesivos requerimientos por parte de esta CNDC, con fecha 12 de febrero de 2020, el consultante efectuó una presentación contestando la totalidad de los requerimientos efectuados por esta Comisión Nacional, pasando las actuaciones a dictaminar.

V. EXIMICIÓN DE TRADUCCIÓN

25. Al respecto y conforme a lo dispuesto en la Resolución SDCyC N° 40/2001, Anexo I punto c) apartado b) “Los documentos que se encuentren escritos en un idioma distinto al español deberán ser acompañados

por sus respectivas traducciones, las que deberán ser realizadas por traductor público matriculado en la República Argentina. Sin embargo, la Autoridad de Aplicación, podrá dispensar este requisito a pedido de parte cuando, a su juicio, la versión en su idioma original o la traducción simple satisfaga las necesidades de información de la Autoridad de Aplicación”; razón por la cual, a criterio de esta Comisión Nacional, el contenido de la documentación, cuya eximición de traducción fuera solicitada por las consultantes, pudo ser satisfecho con la información aportada por las mismas mediante la copia simple del documento original en inglés, de donde surge la fecha de cierre de la operación, por un lado, y el valor de las ventas netas globales, por el otro; por lo cual y habida cuenta la documentación aportada a las actuaciones, se aconsejará al Señor SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR que exima a las consultantes de acompañar la traducción pública del Anexo 1.a) y del Anexo 1.b) acompañados en su presentación de fecha 8 de octubre de 2019.

VI. CONCLUSIÓN

26. En base a las consideraciones expuestas en los párrafos que anteceden, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia aconseja a la SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR DEL MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO disponer que:

(a) la operación traída a consulta, consistente en la adquisición, por parte de INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION de todas las acciones comunes emitidas y a emitirse de RED HAT, INC. se encuentra sujeta a la obligación de notificar estipulado por el artículo 9 de la Ley N° 27.442.

(b) ordenar la apertura de un nuevo expediente electrónico de concentraciones económicas con el formulario F1 presentado el consultante el 29 de julio del 2019 junto con la solicitud de opinión consultiva tratada en el presente Dictamen, y acumularlo al presente expediente;

(c) eximir al consultante, en vistas al análisis de la presente opinión consultiva y en virtud de lo establecido en el Anexo I, punto c) apartado b) de la Resolución SDCyC N° 40/2001, de acompañar la traducción pública del **Anexo 1.a)** y del **Anexo 1.b)** de la presentación efectuada el 8 de octubre de 2019.

27. Asimismo, hacer saber al consultante que la presente opinión consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el expediente de referencia, por lo que, si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ello tornaría inaplicables los conceptos aquí vertidos.

28. Elévese el presente Dictamen a la Señora SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA NACIÓN para su conocimiento.

1 Comunicado de prensa emitido por IBM al momento del cierre de LA TRANSACCIÓN, presentado por las partes sin traducir el 8 de octubre del 2019, N° de orden 20 del expediente electrónico.

2 Banco nación 40.10 al 28 de febrero de 2019

3 Por ejemplo, la Resolución de la Secretaria de Comercio N° 285 de fecha 2 de agosto de 2010, “Hewlett Packard Company y 3Com Corporation s/ consulta interpretación Ley 25.156 (OPI 187); OPI 311 - EX-2018-17681565- -APN-DGD#MP

4 Banco Nación 42.80 al 10 de julio de 2019 (primer día hábil después del cierre de la transacción, que se produjo el 9 de julio del 2019).El ratio entre US\$ 19.032.381 respecto de los US\$ 3.362.069.000 es de 0.56%. Eso aplicado al total del valor de la operación da un total de US\$ 193.760.000, que multiplicado por el valor del dólar estadounidense del Banco Nación tipo vendedor al día posterior de la operación equivale a pesos argentinos \$8.292.928.000.

5 Banco nación 40.10 al 28 de febrero de 2019

